

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0035627-56.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Fernandes Freitas Neto**

Vistos, etc.

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA, R.G. nº 50.207.445, e MELISSA FERNANDES OLIVEIRA PEREIRA, R.G. nº 44.752.847, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, e 35, *caput*, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, isto porque, no dia 05 de maio de 2016, por volta de 13h, na Rua Antonio de Almeida, 277, São Lucas, nesta comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, associaram-se para a prática reiterada ou não do tráfico de entorpecentes, posto

0035627-56.2016.8.26.0050 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que guardavam 59 (cinquenta e nove) invólucros plásticos e 50 (cinquenta) *eppenforfs* contendo cocaína, com massa líquida total de 44,3g (quarenta e quatro gramas e três decigramas) sem autorização legal e regulamentar, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, para comércio com terceiros.

Lavrado o auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), os denunciados foram qualificados (fls. 15 e 23), pregressados (fls. 16 e 24) e receberam nota de culpa (fls. 14 e 25).

Oferecida a denúncia de fls. 01/03 que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 04/55, os acusados foram notificados (fls. 102 e 123), vindo aos autos defesa preliminar conjunta a ambos de fls. 78, subscrita por Dr. Defensor Constituído. A denúncia foi recebida por despacho no dia 10 de outubro de 2016 (fls. 103/104).

Durante a instrução da causa, foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo os acusados interrogados ao final da instrução (tudo gravado em mídia digital acostada aos autos).

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça postula a procedência da ação penal nos termos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

da denúncia (fls. 131/133). O Dr. Defensor Constituído, por seu turno, pede pela absolvição de seus assistidos quanto ao crime prescrito pelo artigo 35, da Lei nº 11.343/06, e que sejam consideradas no calculo da pena a atenuante da confissão e o benefício do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, além das devidas benesses legais.

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 07/10); o auto de exibição e apreensão de fls. 11/12; o laudo de constatação de fls. 45/47, o exame químico-toxicológico de fls. 94/96 e as folhas de antecedentes criminais dos acusados (fls. 68/69 e 71).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente, isto porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que os acusados praticaram somente a conduta descrita pelo artigo 33, da Lei nº 11343/06, devendo ser absolvidos das imputações referentes ao artigo 35, da mesma Lei.

A materialidade do delito é indubitosa, vez que demonstrada nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04) e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, bem como pelo laudo de constatação de fls. 45/47, e pelo exame químico-


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

toxicológico de fls. 94/96, que atesta pelo resultado positivo para cocaína.

A autoria também restou evidenciada, uma vez que demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), bem como pela prova oral colhida.

O policial civil Cesar Moreno Martins, em Juízo, reconheceu o acusado, e contou que realizava operação de combate ao tráfico de drogas no dia em questão, sendo o local já conhecido pela prática de tráfico. Relata que entraram correndo na viela em questão, e se depararam com os acusados sentados numa escada, e entre eles um estojo escolar. Diz que os acusados tentaram empreender fuga, mas não conseguiram, no que os abordaram e abriram este estojo, nele encontrando dinheiro e cocaína. Indica que os acusados, informalmente, confessaram a prática, e disseram ser a primeira vez que traficavam, e que o estavam fazendo para sustentar seus filhos. Dá conta de que havia apenas moradores nas proximidades.

No mesmo sentido é o depoimento do policial civil Fabrizio Piazzentin. Em Juízo, conta que estava em uma operação deflagrada pela oitava seccional para o combate ao tráfico, no que avistaram os acusados numa viela, sentados, com um estojo entre eles, e abordaram-nos. Relata que dentro do estojo havia cocaína, bem como foi encontrada uma quantia em dinheiro pelo policial Cesar. Dá conta de que os acusados confessaram informalmente, indicando que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

estavam traficando para sustentar seus filhos.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual nacional e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras, que, assim como as dos demais, têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser tidos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

— AC — Rel. Synésio de Aquino — RDTJR 7/287).

O acusado Luiz Henrique de Oliveira Almeida, por sua vez, em Juízo, sob o crivo do contraditório, confessou os fatos narrados na denúncia. Contou que estava desempregado há mais de três meses, e precisava sustentar seus filhos.

Da mesma forma, a acusada Melissa Fernandes de Oliveira Pereira confessou, igualmente, a prática delitiva. Contou que se envolveu com o tráfico apenas para sustentar seus filhos pequenos. Dá conta de que vendia drogas com seu companheiro, Luiz Henrique, há cerca de duas semanas.

A Jurisprudência é pacífica quanto ao valor probatório da confissão:

“A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário” (TACrSP — RJDTACRIM 40/221).

Com efeito, merece todo o crédito a confissão dos réus, tendo em vista que coerentes com os depoimentos dos policiais, e que confessaram, também, na fase inquisitiva, restando


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

demonstrada sua culpabilidade de forma estreme de dúvidas.

Assim, diante do contexto probatório, frente às confissões dos réus e dos depoimentos lógicos, coesos e sequenciais dos policiais civis, imperioso se faz um decreto condenatório.

Quanto ao destino da droga apreendida, não se discute que os entorpecentes destinavam-se à finalidade de tráfico, e não de uso. Com efeito, a quantidade de entorpecentes encontrada (fls. 11/12, 45/47 e 94/96), consistente em 44,3g (quarenta e quatro gramas e três decigramas) de cocaína, distribuídos em 109 (cento e nove) porções, é bastante grande e variada, típica da atividade de traficância, bem como foram encontrados R\$63,00 (sessenta e três reais), em notas variadas, com os acusados; afastando, assim, seja o delito desclassificado para o artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

De se notar, no entanto, que para o crime de associação para o tráfico, é imprescindível o caráter permanente da *societas criminis*, tendo em mente que uma associação eventual trata-se de mero concurso de agentes, e não do tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/06. Como se observa, o dolo de se associar com estabilidade e permanência não restou claramente demonstrado nos autos. Nesse sentido:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“(…) O delito previsto no art. 35, da nova lei de droga, pressupõe, para o seu reconhecimento, a demonstração do dolo de associar-se de forma estável. É necessário que se identifique na *societas criminis* o caráter permanente, algo que não se confunde com a mera co-autoria (…).” (Apelação Criminal nº 1.0024.07.566886-3/001(1), Rel. Hécio Valentim, Publ. Em 30/08/2008).

Observa-se, portanto, que não foram produzidos elementos de prova suficientes que efetivamente apontassem os acusados como autores do indigitado delito de associação para o tráfico. Assim, diante de elementos de convicção que tais, entendo de rigor sua absolvição por este crime que lhes foi imputado, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câm., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in *Jurisprudência Penal e Processual Penal*, vol. 8, pág. 313).

E mais: “ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Ac. un.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

da 6a. Câm., de 20-4-76, na Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI, idem, pág. 319).

Assim, diante de tais elementos de convicção, não restam dúvidas de que o proceder dos acusados se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na denúncia, com exceção ao crime de associação, sendo a condenação de ambos medida necessária, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA, filho de Lucicleide de Oliveira e Luiz Carlos Cardoso de Almeida Junior, e MELISSA FERNANDES OLIVEIRA PEREIRA, filha de Eliane Aparecida Fernandes e Joaquim Manuel Pereira Junior, como incurso nas sanções do artigo 33, "Caput", da Lei nº 11.343/06; absolvendo-os das imputações do crime do artigo 35, da mesma Lei, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, imponho aos réus a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a Lei.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fixei a pena no mínimo legal, isto porque os réus são primários (fls. 68/69 e 71), não ostentam antecedentes criminais, e confessaram espontaneamente a prática delituosa.

De se aplicar a norma do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, isto porque os réus são primários, não se dedicam a atividades criminosas, e nem integram organização criminosa, motivo pelo qual reduzo a pena inicial em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a Lei.

Incabível, ademais, a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritivas de direitos, devendo ser aplicada a norma contida no artigo 44, da Lei nº 11.343/06, que veda, expressamente, a sua conversão em restritivas de direitos.

E nesse passo é bom lembrar a lição do mestre Guilherme de Souza Nucci: "...Nenhuma inconstitucionalidade existe, pois não se fere a individualização da pena. Cuida-se de política criminal do Estado, buscando dar tratamento mais rigoroso ao traficante..." (In. Leis Penais e Processuais comentadas, p. 397, 5ª Ed., RT)

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Assim sendo, torno aquelas penas definitivas à mingua de causas de modificação, devendo as penas serem cumpridas em REGIME ABERTO, nos termos do que reza o artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, isto porque os réus são primários (fls. 68/69 e 71) e menores de vinte e um anos de idade; concedendo-lhes o direito de apelar em liberdade.

Expeçam-se alvarás de soltura com as cominações de praxe.

Custas “ex lege”.

P. R. I. e C.

São Paulo, 29 de março de 2017.

JOSÉ FERNANDES FREITAS NETO

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**